

1500334-08.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, quando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500334-08.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-08.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081772/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 16957971 - 2º Distrito Policial de Lorena, 12/21/213 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2081772 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 12/21/213 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO GARCIA CALIXTO DA SILVA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de THIAGO GARCIA CALIXTO DA SILVA e VINÍCIUS ARISTIDES VIEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, na qual lhes são atribuídas a prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, pelos fatos narrados na peça inicial de fls. 150/152.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados, apresentando defesas prévias (em conjunto, às fls. 222/235). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida no dia 30/06/2021, e designou-se audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 56, da Lei de drogas (fls. 236/241).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas e os informantes judiciais arrolados pelas partes, sendo os réus, ao final, interrogados. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, com a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 296/300).

Por sua vez, a defesa dos acusados, requereu a improcedência da ação penal, por ausência ou carência probatória, forte no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal – CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição da pena do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 304/311).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As materialidades delitivas encontram-se cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), fotografias (fls. 30/43), laudo de constatação provisória (fls. 23/25) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 180/182), cujos resultados foram positivos para “cocaína e tetrahidrocannabinol – THC – maconha”, substâncias presentes na lista “F1”, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como as provas orais existentes nos autos.

Com relação às autorias, tenho que estas também restaram confirmadas, comprometendo a dupla. A começar pelo próprio estado flagrancial. Senão vejamos.

O investigador de polícia, Rafael Ferreira Correia, contou que, no dia dos fatos, foi alertado que o corréu Thiago receberia uma grande “carga” de entorpecentes. Esclareceu que, por já ser o acusado conhecido “nos meios policiais” pelo seu envolvimento pretérito com o vil comércio, tratou de levantar o seu endereço, e montar uma campanha no local e nas redondezas, a fim de averiguar a veracidade daquela informação recebida. Passado algum tempo, percebeu a chegada ao local de um veículo modelo “VW/Gol”, e Thiago saindo de sua residência para ir ao seu encontro, o que despertou sua desconfiança. Na sequência, ambos foram abordados, ocasião em que o corréu Vinícius foi identificado como condutor do automóvel. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse da dupla. Porém, no interior do carro foi encontrada droga, assim como dentro da casa de Vinicius. De acordo com o depoente, durante conversas informais com os réus, Vinicius admitiu que estava guardando as drogas para Thiago, o que o levou a acreditar que este seria o “patrão” e aquele, o “funcionário”. Já Thiago negou qualquer envolvimento com o corréu e com os ilícitos localizados no veículo. Contudo, ainda segundo o agente da lei, no decorrer das investigações, após a autorização judicial para análise dos celulares apreendidos com os acusados no momento das prisões deles, constatou-se que, na verdade, Vinícius era o proprietário dos entorpecentes, e Thiago era a pessoa responsável pela negociação e venda destes, através da análise de conversas por meio de um famoso aplicativo. Esclareceu que na casa de Thiago não foi encontrado nenhum ilícito. Questionado sobre o aspecto das residências dos dois, a testemunha afirmou que os imóveis ficam em bairros populares, sendo que a casa de Thiago é de bom padrão, enquanto que a de Vinícius mostrava-se um pouco bagunçada, por nela residirem várias pessoas.

Seu companheiro de Polícia Civil, Alexssander Kasuo Nokai apresentou narrativa semelhante.

Ouvido na condição de informante judicial, Rodolfo Henrique Teodoro da Silva, enteado de Thiago, contou que estava dormindo e acordou com os policiais já dentro

de sua casa, na companhia dos acusados. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado na residência. Relatou que viu Vinícius, em duas ocasiões, naquele imóvel, pois este levava o seu automóvel para Thiago, dono de uma oficina mecânica no local, consertar. Por fim, disse que presenciou a apreensão da droga no veículo, acompanhando a ação policial na casa de Vinícius, local onde mais entorpecentes foram achados.

Também ouvida naquela mesma condição (informante), Amanda Aristides Vieira da Silva, irmã de Vinícius, afirmou que o carro utilizado por ele no dia dos fatos ("VW/Gol"), é de sua propriedade. Contou que o carro estava parado no quintal da casa e que o utilizava para guardar objetos diversos. Narrou que os policiais estiveram na residência deles, a reviraram e localizaram mais entorpecentes debaixo de uma escada que dá acesso ao imóvel, porém, do lado externo da casa. Afirmou que seu irmão sempre trabalhou e, à época, estava "de aviso prévio". Aduziu que Vinícius chegava em casa, por volta das 17h a 18h, do trabalho, e estudava pela internet, até dormir. Por fim, disse que seu irmão não possuía grandes recursos financeiros.

Já o corréu Thiago, durante sua autodefesa, negou os fatos. Contou que Vinícius fora até a sua casa para que consertasse seu veículo, já que sua oficina fica no mesmo imóvel em que reside. Afirmou que o corréu era cliente da oficina anterior e, na casa dele, chegara atendê-lo apenas uma vez. De acordo com o interrogando, em sua casa nada de ilícito fora apreendido, contudo, como os policiais localizaram drogas dentro do carro de Vinícius, estes levaram todos para a residência deste corréu, onde mais entorpecentes foram apreendidos.

Por outro lado, Vinícius confessou parcialmente os termos da exordial acusatória. Admitiu que, de fato, estava na posse das drogas encontradas em seu veículo e, como este havia apresentado problema mecânico, passou na oficina de Thiago no afã de resolvê-lo. Negou que Thiago soubesse dos entorpecentes. O interrogando também assumiu a responsabilidade pelos narcóticos encontrados em sua casa, negando, de outra banda, a posse dos apetrechos descritos no auto de apreensão. Disse, ainda, que os seus familiares não sabiam de nada, pois estava morando apenas quatro dias com eles naquele imóvel. Na sequência, contradizendo-se, afirmou que não havia nada de ilícito em sua casa. Questionado sobre as conversas mantidas com Thiago, disse desconhecer-las, embora confirmando que seu celular fora apreendido pelos policiais.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a negativa do corréu Thiago é absolutamente refratária às demais provas dos autos, não convencendo este Juízo.

De outro lado, a despeito da confissão de Vinícius, à luz do interesse público em jogo, em especial, a culpabilidade de Thiago, o qual refuta a autoria delitiva, passo também a analisar a postura daquele acusado frente as demais provas, a fim de verificar a sua consistência frente aos demais elementos de prova.

Saliente-se, de início, exceto se a palavra de Vinícius soasse inverídica, por outros elementos de convicção, o que não aconteceu no presente caso, a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida por esse increpado, no caso destes autos, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro para a condenação dele próprio, bem como implica o corréu Thiago.

Veja-se a explicação de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Isso ocorre porque os depoimentos dos policiais civis, que realizaram as prisões em flagrante dos increpados, corroboraram com a confissão de Vinícius, conforme se viu

acima.

Neste ponto, insta registrar que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Frise-se que esses agentes do estado, que testemunharam nestes autos, nunca haviam tido contato com Thiago, conhecendo-o apenas por registros policiais, e desconheciam, completamente, o corréu Vinicius.

Afinal, como acreditar que um policial; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso da militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, ele próprio, violá-la, com o fito de incriminar um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só. Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco ou afinidade, como no caso dos informantes judiciais apresentados pela defesa, nestes autos; ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõe a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo

justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Diante disso, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. O mesmo vale para confissão do réu Vinicius, por exemplo. Não nos encontramos mais nos primórdios do processo penal. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas. Todas são relativas!

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput" do CPP, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, observo que os depoimentos dos agentes da lei são aptos a confirmar a confissão espontânea de Vinicius, em linha com o conjunto probatório dos autos, restando insofismável a veracidade de suas declarações, com relação à posse dos entorpecentes, e autoria criminosa.

Neste ponto, confirmada a confissão de Vinicius, tenho que a autoria de Thiago restou igualmente comprovada nos autos, na medida em que, se aquele acusado estava na posse de grande quantidade de entorpecentes em seu veículo, o estacionando em frente à casa/oficina de Thiago, é porque, de fato, os entregaria à este réu. Afinal, havia também denúncia anônima anterior assim indicando, tal como revelado pelos policiais civis!

Outra prova irrefutável é o laudo pericial da gravação das conversas nos celulares dos acusados (fls. 130/139).

Nela, cujo teor foi corroborado em juízo pelos depoimentos dos investigadores de polícia, ora testemunhas de acusações, é possível notar que Thiago encaminha áudios

de possíveis compradores dos entorpecentes a Vinícius, combinando o local da entrega das drogas e recebimento do dinheiro e de futuras negociações. Da simples leitura de tais diálogos, em alguns momentos bem explícitos (“Eles estão sem pó desde ontem” – fl. 136, áudio de Thiago para Vinícius), e em outros, nem tanto, por conta da utilização de gírias mais complexas (“biquear”, retirar a caminhada”, “ele queria essa pipoca pra já fazer um teste”, “lojinha dele na Vila Geny”, “são 7 de óleo e 9 de Ás de ouros” – fls. 136/137, conversas entre os réus), é possível perceber que ambos falam sobre o vil comércio.

Existe até mesmo uma fotografia nas conversas entre os réus, dos entorpecentes embalados, em formato de tijolo, com um adesivo de uma carta de “Ás de ouros”, nomenclatura utilizada por eles naquelas conversas, referindo-se à droga ilícita (p. 135).

Nem se argumente, de outro lado, que os interlocutores dessas conversas não seriam os acusados, vez que os celulares periciados foram apreendidos em suas posses. Ademais, existem áudios enviados por Vinícius à Thiago, nos quais aquele o identifica como “Thiago”, e que o próprio faz referência a sua oficina.

Já no diálogo transcrito às fls. 134, Thiago sugere a Vinícius que levasse os entorpecentes para a casa de um terceiro. Contudo, este último disse não querer envolver outras pessoas e asseverou: “Eu encosto aí como se fosse cliente seu, desbaratinado mano” (sic).

Mas não é só. Ao contrário dos policiais civis (fls. 03/04 e 05/06), os quais mantiveram a versão que haviam apresentado em sede policial, após alguns meses, a este Magistrado, Vinícius preferiu o silêncio em um primeiro momento (p. 10), enquanto Thiago apresentou uma “estória” que emprestou o celular para Vinícius, diversas vezes, para que este fizesse uma “caminhada” (p. 08/09).

Ora, se por um lado, tal postura revela o exercício de um direito assegurado constitucionalmente a Vinícius, de outro, causa estranheza que este não tenha revelado à autoridade policial que fosse o único e exclusivo responsável pelos narcóticos apreendidos, fato que poderia ter evitado a prisão de Thiago.

Esclareça-se que ambos foram interrogados na presença de seus respectivos advogados constituídos, em sede policial (fls. 08/09 e 10).

Thiago, aliás, sequer ratificou em Juízo a versão apresentada perante o delegado de polícia, de que havia emprestado o seu celular para Vinícius.

É importante mencionar, outrossim, que o argumento defensivo no sentido de que os increpados não ostentavam eventual lucro oriundo desse comércio espúrio, residindo em imóveis populares, não é capaz de afastar a autoria delitiva dos indigitados, diante de provas tão robustas em seus desfavores, considerando, também, que o êxito financeiro não é requisito para o reconhecimento dessa autoria.

Assim, por qualquer lado que se observa os fatos ora “sub judice”, exsurtem a autoria criminosa de ambos os réus, seja de Vinícius pela propriedade dos entorpecentes, seja de Thiago pela negociação com terceiros para vendê-los.

Ademais, sem prejuízo da confissão de Vinícius e da palavra dos policiais, Thiago não apresentou uma prova sequer do que alegou, para demonstrar estratégia criada para incriminá-lo, nem apontou motivo sério que permitisse tal conclusão, logo, não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, “caput”, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Por fim, sobre as condutas tipificadas no artigo 33, da Lei 11.343/06, esclareço ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente duas dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, diante das quantidades e diversidade de entorpecentes e balança de precisão, bem como daquelas conversas entre os acusados, sobre a negociação para venda a terceiros, trazidas aos autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, reconhecida a autoria delitiva, é o caso de condenação dos réus, pelo crime do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com relação ao crime do artigo 35, "caput", da Lei em assunto, os acusados têm o mesmo destino.

De acordo com o conjunto probatório dos autos, existe prova sólida para se concluir, com segurança, que os réus estavam associados, para o comércio ilícito de entorpecentes.

Veja-se que a degravação daqueles diálogos entre os increpados revelou o "animus associativo", a estabilidade, permanência e organização entre eles, com funções pré-determinadas, desde data não estipulada, mas, até o dia 23/03/2021.

Ressalto que os elementos dos autos apontaram para a seguinte repartição de tarefas: Vinícius obtinha e armazenava as drogas, enquanto Thiago as negociava, vendendo-as.

Insta salientar que a estabilidade e permanência são facilmente constatadas, examinando as datas das conversas, anterior ao tráfico aqui em assunto, e as diversas tratativas entre os acusados para a venda de narcóticos a outros traficantes, os quais provavelmente os venderiam no varejo, conforme aqueles diálogos.

Em reforço a essa conclusão, trago à baila o trecho da conversa dos réus, com expressões que ratificam a habitualidade e permanência, considerando, ainda, os

valores relacionados, que embora não fossem todo destinado aos réus, eram movimentado por eles, nessa vil empreitada:

Thiago: "O mano tá perguntando aqui, fora as 10 dele da trator, cê consegue arrumar essas 20 da trator até quando (...)?"

Vinícius: "Até na sexta-feira já tá no pente, entendeu!? (...) Eu vou também mandar uma moeda pros meus amigos, pra cima lá, entendeu!? Eu vou mandar descer mais. (...)".

(...)

Thiago: "(...) se desse pra mim soltar uma da pipoca só pra mão do Gordão, por Gordão biquear, já era para ele vender e ir metendo marcha na lojinha dele na Vila Geny, entendeu!? E isso o hora ia bater das 10, 10:30 pra irmã dele vir fazer o pagamento das caminhadas nossas, entendeu parça!? (...) O motorista dele é o que tá vindo lá de cima, de Minas, que ele vai levar pra lá essa caminhada".

Vinícius: "Então eu vou retirar ali ainda do moço ali ainda, também, entendeu!? Vou passar ali, fazer esse orçamento que tá combinado lá já com a moça. Não pode deixar meu freguês também na mão né e já vou retirar depois a pipoca, entendeu!? Já chego com tudo junto aí!"

Vinícius: "Thiago, o total de tudo vai dar 286 mil" (sic).

De fato, presentes elementos a demonstrar a "associação" entre eles para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, conforme escólio de NUCCI, Guilherme de Souza, "in" Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 334:

"Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. (...) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum".

Portanto, devida a condenação de ambos, também, pelo delito de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, "caput", da lei citada).

Passo à calibragem penal, seguindo a ordem da denúncia.

a) THIAGO GARCIA CALIXTO DA SILVA:

a.1) Crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06:

Nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a natureza, quantidade, personalidade e conduta social.

Deste modo, conforme folha de antecedentes e certidão criminal de fls. 284/286 e 282/283, respectivamente, ainda que o réu seja primário e sem antecedentes criminais, a extraordinária quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos (9,05 quilogramas, peso líquido, de "cocaína", e 15,12 quilogramas, peso líquido, de "maconha"), apontam para maior risco ao bem jurídico tutelado por este tipo penal, a saúde pública, não podendo este julgador, aplicar a mesma sanção devida à culpabilidade normal à espécie.

Logo, sua pena-base deve ser fixada elevada pela metade (1/2) do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem valoradas.

Anoto que a condenação apontada pelo Ministério Público, como ensejadora da reincidência (0000666-69.2013.8.26.0220), fora reformada pelo Tribunal de Justiça, sendo extinta a punibilidade de Thiago, com base no artigo 76, da Lei 9.099/95, razão pela qual inviável a utilização de tal registro para esse fim, forte no § 4º, do artigo citado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - (...) AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - A condenação mencionada caracterizadora da reincidência refere-se a feito em que houve transação penal - Conforme dispõe o § 4º do artigo 76 da Lei 9.099/95, a aceitação da transação penal não importará em reincidência. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0044818-69.2012.8.26.0114; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).

Não havendo outras circunstância modificadoras das penas, torno-as definitivas como fixadas acima.

Ao contrário do pedido defensivo, observa-se que Thiago não preenche os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado e não, apenas, devido às quantidades exorbitante e diversidades de entorpecentes apreendidos, mas sim porque está, também, sendo condenado pelo crime de associação criminosa, conforme se viu em momento anterior.

Como se sabe, não se dedicar às atividades criminosas ou não integrar organização criminosa são condutas que não coadunam com o agente que se associou de forma estável e permanente para o fim de praticar as condutas dos artigos 33, "caput" e § 1º, e 34, da Lei 11.343/06, como o fez este acusado, que ora está sendo condenado, também, pelo crime do artigo 35, da lei em assunto.

Mesmo entendimento do C. STJ e do E. TJSP em julgados semelhantes e recentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021); e

“Tráfico de Drogas e Associação ao tráfico de Drogas - (...) Reprimendas mantidas - Recursos não providos. Tráfico privilegiado - Impossibilidade - Associação criminosa configurada - Comportamento voltado ao delito - Dedicção à atividade criminosa comprovada - Reprimendas mantidas - Recursos não providos. (...) - Recursos não providos”. (TJSP; Apelação Criminal 1500553-90.2020.8.26.0189; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021) (Originais sem as marcações).

a.2) Crime do artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06:

Como já apontado, Thiago não possui condenações pretéritas.

No que tange à conduta, ora em tela, malgrado sua gravidade, não extrapola a tipificação penal, à luz da quantidade de pessoas envolvidas.

Contudo, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 24 quilos) relacionados a esta associação, o que lhe dá magnitude, entendo razoável estabelecer a pena-base, a fim de distinguir de outras associações criminosas que se ocupam de menores quantidades, em 1/6 (um sexto) acima do patamar raso, ou seja, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, aqui já em definitivo, à míngua de outras circunstâncias modificadoras das penas.

Superada a dosimetria dos delitos, decorrentes de condutas distintas, em momentos diferentes, de crimes de espécies diversas, de rigor o reconhecimento do concurso material (artigo 69, do Código Penal), o que resulta em um total de pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.566 (mil quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

b) VINÍCIUS ARISTIDES VIEIRA DA SILVA:

b.1) Crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.43/06:

Anoto que este réu também é primário e sem registros penais desabonadores, conforme os documentos de fls. 287/288 e 289/290.

Todavia, conforme falado na dosimetria de Thiago, observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei de drogas, tenho que a conduta de Vinicius merece maior reprovação, tendo em vista as mesmas circunstâncias judiciais expostas acima na dosimetria do corréu, as quais ora adoto, deixando de repeti-las, para evitar a tautologia.

Logo, mantendo a proporcionalidade, a basilar será estabelecida em 1/2 (um meio) acima do mínimo legal, ou seja, 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Logo, atenuo as penas em 1/6 (um sexto), passando estas ao patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, as quais torno definitivas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Inviável reconhecer em seu favor a redutora prevista no parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei de Drogas, não obstante ser primário e de bons antecedentes, vez que está sendo condenado, pelo crime do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, o que já afasta a incidência desse privilégio.

Veja-se mais essa jurisprudência:

"1-) Apelações criminais. (...) Por fim, a existência de associação para o tráfico, de per si, é suficiente para afastar a causa de diminuição da pena contida no art. 33, § 4º, na medida em que evidencia a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, conforme entendimento do Preclaro Superior Tribunal de Justiça. Inexistem causas de diminuição e de aumento, as penas acima ficam definitivas. (...) 9-) Recursos presos (fls. 515). Nunca é demais lembrar que "A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência" (Súmula nº 9 do ESTJ). RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7". (TJSP; Apelação Criminal 1502215-90.2018.8.26.0664; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020) (Sublinhado meu).

b.2) Crime do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06:

Conforme exposto acima, em análise das diretrizes traçadas pelo artigo 59, do

Código Penal, verifico que Vinicius não possui maus antecedentes.

Porém, a fim de manter a proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, considerando a fração aplicada ao corréu Thiago, a este mesmo delito, conforme as circunstâncias mencionadas acima, vez que são as mesmas para ambos, será adotada a mesma fração de aumento na proporção de 1/6 (um sexto) acima do piso legal, ou seja, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, aqui já em definitivo, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Superadas as dosimetrias de cada crime, reconheço o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal). Assim, as penas devem ser somadas, resultando em um total de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.441 (mil quatrocentos e quarenta e um) dias-multa.

Com relação ao regime inicial de cumprimento das penas, será o fechado, para ambos os réus, em vista das circunstâncias concretas destes autos acima expostas, começando pelo "quantum" da pena aplicada, passando pela quantidade e diversidade dos entorpecentes, sem prejuízo da apreensão da balança de precisão, forte no artigo 33, §§ 2º, alínea "a", e 3º, do Código Penal.

Veja-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. (...) Impossível aplicar o redutor, diante das peculiaridades concretas do caso. Quantidade e diversidade de entorpecentes denota envolvimento perene do réu em atividade de tráfico estruturada. Regime fechado adequado à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0007020-71.2018.8.26.0047; Relator: Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/02/2020) (Ênfase na reprodução).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos acusados, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

a) condenar THIAGO GARCIA CALIXTO DA SILVA, qualificado nos autos, por violação dos tipos penais previstos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhe uma pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e multa de 1.566 (mil quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal; e

b) condenar VINÍCIUS ARISTIDES VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, por violação dos tipos penais previstos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-

lhe uma pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e multa de 1.441 (mil quatrocentos e quarenta e um) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do "sursis" penal, à vista do montante de pena aplicado aos réus, assim como tais medidas mostrar-se-iam insuficientes e ineficazes à reprovação, dada a hediondez do crime de tráfico.

Nego-lhes, ainda, o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva dos implicados se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Além disso, as penas relativamente altas impostas aos acusados e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar os réus que permaneceram segregados durante toda a instrução processual, agora, depois de condenados, sem que tenha dado o tempo da detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também, garantir a ordem pública, recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeçam-se as guias de execução provisória, conforme o caso.

Custas pelos vencidos.

Caso ainda não se tenha feito, em cumprimento às decisões de fls. 97/100 e 155/157, encaminhem-se as drogas apreendidas, bem como os demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Com relação aos celulares e o automóvel, "VW/gol 1000l", placas "CDK5496", apreendidos às fls. 18/20, decreto a perda em favor da União, vez que utilizados neste comércio espúrio, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Translade-se cópia aos autos em apenso (0001968-37.2021.8.26.0323), instaurados para cumprimento dos artigos 61 e 62 da Lei 11.343/2006, com redação determinada pela Lei 13.840/2019, expedindo-se o necessário e dando prosseguimento naqueles autos.

Anoto que, se os aparelhos celulares não apresentarem mais conteúdo econômico, após a devida certificação nos autos, fica autorizada suas destruições, observadas as disposições normativas pertinentes.

Com relação à perda do automóvel, que o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu em recurso extraordinário, com repercussão geral, o Tema 647, que o perdimento do bem, como no caso destes autos, não é necessária a habitualidade na atividade ilícita,

logo, como restou cabalmente comprovado que Vinicius se utilizou desse automóvel para guardar e transportar a droga, frise-se, ainda que, somente nesta ocasião, é o caso de decretar o seu perdimento.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição. 3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O Supremo Tribunal F [...]” (STF; RE 638491; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. LUIZ FUX; Julgamento: 17/05/2017; Publicação: 23/08/2017).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se as guia de execução definitiva, conforme o caso; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 07 de janeiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA